

1500155-05.2021.8.26.0062

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE FELIZ DA SILVEIRA

Comarca: Bariri

Foro: Foro de Bariri

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/03/2022

... 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).

Segundo se apurou, no dia dos fatos, os acusados praticavam tráfico de drogas e, para tanto, mantinham em depósito, na casa do INDICIADO GILBERTO, as drogas descritas no item "1".

Ocorre que Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina e, com base em informações anteriores que davam conta que os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bariri

Foro de Bariri

1ª Vara

Av. Claudionor Barbieri, nº 488, Bariri-SP - cep 17250-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500155-05.2021.8.26.0062 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500155-05.2021.8.26.0062

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2051608/2021 - DEL.POL.BARIRI, 11269779 - DEL.POL.BARIRI, 961/21/406 -

DEL.POL.BARIRI, 2051608 - DEL.POL.BARIRI

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MAICON ANDREI SCUDILIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE FELIZ DA SILVEIRA

1. RELATÓRIO

O ilustre Representante do Ministério Público do Estado de São Paulo, em exercício neste Juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial, ofereceu denúncia em face de Maicon Andrei Scudilho e Gilberto Nicolas Manzato Forcin, dando-o como incurso nas sanções previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, pela prática, em tese, dos seguintes fatos delituosos:

1. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 23h, na Rua Professor Alide Ursulano Cardoso, 130, Jardim Domingos Aquilante, nesta cidade e comarca de Bariri/SP, GILBERTO NICOLAS MANZATO FORCIN, qualificado às fls. 03/04 e MAICON ANDREI SCUDILIO, qualificado às fls. 03/04 e, previamente ajustado e com identidade de propósitos, mantinham em depósito e traziam consigo, sem autorização legal, 3.09 kg (três quilos e nove decigramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "maconha", acondicionadas em 03 (três) embalagens do tipo tijolos e 01 (uma) porção de cocaína, com peso bruto de 517g (quinhentos e dezessete gramas) (cf. auto de exibição e apreensão de fls.

05/06, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 09/10 e fls. 11/12).

2. Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, nas circunstâncias de local acima descritas e anteriormente ao fato narrado no item "1", MAICON ANDREI SCUDILIO, GILBERTO NICOLAS MANZATO FORCIN, já qualificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de drogas).

Segundo se apurou, no dia dos fatos, os acusados praticavam tráfico de drogas e, para tanto, mantinham em depósito, na casa do INDICIADO GILBERTO, as drogas descritas no item "1".

Ocorre que Policiais Militares realizavam patrulhamento de rotina e, com base em informações anteriores que davam conta que os INDICIADOS realizavam tráfico de drogas na região, resolveram montar campana. Para tanto, estacionaram a viatura próximo a residência de GILBERTO, sendo que de imediato passaram a visualizar intensa movimentação de pessoas, entrando e saindo do imóvel.

Em determinado momento observaram MAICON ANDREI entrando no imóvel, razão pela qual os Policiais Militares decidiram passar defronte a residência de GILBERTO. Neste ínterim, visualizaram MAICON saindo da casa e trazendo junto de si uma bolsa de ombro escura, sendo que na sequência saiu o INDICIADO GILBERTO.

Diante da suspeita que pairava sobre os INDICIADOS, os Policiais Militares optaram por abordá-los, contudo, ao descerem da viatura, MAICON e GILBERTO empreenderam fuga, tomando rumos opostos. Em ato contínuo, os Militares foram no encalço dos indiciados, sendo que durante a fuga presenciaram MAICON jogando a bolsa sobre o muro de uma casa, contudo, a bolsa acabou ficando presa na concertina da residência. O INDICIADO MAICON conseguiu empreender fuga da ação policial. Por outro lado, GILBERTO foi abordado, mas durante a revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, razão pela qual foi liberado.

Os Policiais Militares lograram êxito em recuperar a bolsa dispensada pelo INDICIADO MAICON, em cujo interior havia as drogas descritas no item "1". Na sequência, retornaram à casa de GILBERTO, contudo, não mais o encontraram.

Na sequência, de posse de informações do setor de investigações que apontavam que os INDICIADOS praticavam o tráfico ilícito de drogas, os Policiais procederam-se o regular reconhecimento pessoal e de objeto (fls. 22/23).

Assim, o comércio ilícito de entorpecentes praticado pelos INDICIADOS se infere pela narrativa dos Policiais Militares que perceberem a atitude suspeita dos indiciados, já conhecidos dos meios policiais pela prática do tráfico ilícito de drogas, pelas condições em que se desenvolveu a ação, bem como pela natureza dos tóxicos apreendidos e a forma em que estavam acondicionados (grande quantidade e variedade de droga apreendida).

Recebida a denúncia, os réus foram regularmente notificados (fls. 93 e 95) e apresentaram defesas prévias, por defensor dativo nomeado (fls. 104/106).

Em instrução (audiência virtual realizada por meio de videoconferência - ferramenta Microsoft Teams), ausente 01 (uma) testemunha, oportunidade na qual a defesa desistiu de sua oitiva, bem como foram ouvidas outras 06 (seis) testemunhas e os réus interrogados ao final (fl. 165).

Em alegações finais, por memoriais, o Ministério Público pugnou, em síntese, pela condenação nos termos da denúncia, uma vez comprovadas a autoria e materialidade do crime. Em relação à dosimetria da pena, requereu sua majoração em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas na primeira fase; nada na segunda fase, como também, na derradeira e última fase, o não reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 a ambos os réus. Por fim, postulou pela aplicação do cumprimento em regime inicial no fechado, tal como a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena.

A Defesa de ambos os réus, por seu turno, em memoriais, protestou pela improcedência da ação penal, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do CPP; subsidiariamente, pelo reconhecimento do tráfico em sua modalidade privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), convertendo-se em pena restritivas de

direitos, bem como que os réus possam apelar em liberdade.
É o relatório. Fundamento e decido.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, constata-se que o feito tramitou regularmente, sendo observadas todas as etapas procedimentais, tal como assegurados os direitos e garantias inerentes à defesa. Dessa forma, não havendo nulidades a serem sanadas, tampouco questões preliminares ou prejudiciais a serem enfrentadas, assim passo ao exame do mérito.

A materialidade do fato está comprovada através do boletim de ocorrência (fls. 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 11/12), do laudo de constatação provisória de substância ilícita (fls. 15/18), pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 157/163), bem como pela prova testemunhal produzida, colhida sob o crivo do contraditório.

Da mesma forma, a autoria, está plenamente demonstrada e recai sobre os acusados. Tanto em sede policial, quanto em juízo, a testemunha Emerson Luís Albranti, policial militar, narrou que foram recebidas denúncias informando que iria chegar grande quantidade de drogas para Nicolas, ocasião na qual ficou na esquina de uma escola, próximo a residência dele, observando o local junto de seu parceiro. Nesse ínterim, ao avistarem uma pessoa (Andrei) indo em direção a casa, aproximaram-se com a viatura para efetuar a abordagem de ambos. Em abordagem, separaram-se e foram em direção aos réus, momento esse em que Andrei, que estava com uma bolsa, iniciou fuga, bem como Albranti solicitou o reforço de seu parceiro (policial militar Moraes). Em perseguição, Andrei foi visto jogando fora a bolsa e, de seguida, teve sucesso em efetuar a fuga. Destacou que seu parceiro conseguiu abordar o Nicolas, tal como fez uma vistoria preliminar nele e depois seguiu em direção ao Andrei. Após, em vistoria no local, notaram que a bolsa ficou presa em uma concertina, assim como, dentro dela, havia 03 (três) quilos de maconha e 500 (quinhentos) gramas de cocaína. Em ato contínuo, foram em direção à residência de Andrei, local onde não o encontraram, bem como não tiveram sucesso em localizar Nicolas. Acrescentou que tentaram de várias formas encontrar ambos, porém sempre sem sucesso. Indagado pela acusação, sustentou que as informações preliminares apontavam que as drogas tinham como destinação a casa de Nicolas. Esclareceu que, de princípio, não reconheceu Andrei, mas conforme se aproximou do local, teve sucesso em reconhecê-lo, tal como ele estava vindo de sua casa (que fica a um quarteirão de distância) e seguindo em direção à casa do Nicolas. Adicionou que Andrei veio de sua residência com nada em mãos e, depois de entrar na casa do Nicolas, saiu com a bolsa contendo as drogas apreendidas, como também conhecia os réus devido a serem conhecidos nos meios policiais. Questionado pela defesa, alegou não lembrar do horário exato da abordagem, mas que foi, no máximo, até às 22h00min, bem como a bolsa em questão era de tila colo e de cor preta. Por fim, recontou que foi seu parceiro quem abordou o Nicolas.

Com efeito, tanto em sede policial, quanto em juízo, a testemunha Anderson Luís Bettini de Moraes, policial militar, em síntese, prestou os mesmos depoimentos da testemunha Albranti. Perguntado pela acusação, confirmou que a residência do Nicolas é uma casa de esquina e que os réus, no momento da abordagem, seguiram em direções opostas, assim como eles eram conhecidos nos meios policiais. Recontou que Andrei veio a adquirir a bolsa depois de visitar a casa de Nicolas. Por fim, interpelado pela defesa, aduziu que o momento da abordagem ocorreu entre às 22h00min e 22h30min e que essa foi a única vez em que conseguiu abordar o Nicolas. Por seu turno, em depoimento prestado em juízo, a testemunha José Da Dalto, policial civil, relatou que não participou dos fatos. Quanto ao réu Andrei, diante das denúncias, detalhou que ele não participa do tráfico de drogas, mas que armazena drogas para outros traficantes. Com relação à Nicolas, aludiu que existem várias informações de que ele se dedicava ao tráfico ilícito de droga, bem como já foram cumpridos mandados de busca e apreensão em sua residência, porém, devido a pouca droga localizada, resultou em 02 (dois) termos circunstanciados. Acrescentou que Nicolas é bem conhecido nos meios policiais e desconhece se ele possui

trabalho.

Waldemar Antônio Mazini Júnior, cunhado de Andrei, testemunha na condição de informante, historiou que, no data dos fatos, estava na casa de sua irmã e do Andrei, ocasião na qual saiu junto dele em direção à sorveteria e, em seguida, em direção ao "Dinho Corradini". Nesse ínterim, por volta das 22h00min ou 22h30min, sua irmã o ligou falando que o Albranti estava procurando por Andrei devido a ele ter corrido com uma mochila, porém eles estavam juntos. Após, explanou que Andrei ficou assustado e retornou para casa, bem como existe uma grande distância do local onde estavam até a residência do réu. Indagado pela acusação, alegou que os fatos ocorreram em uma sexta-feira.

A testemunha José Antônio Rodrigues, expressou que presenciou a abordagem do Nicolas, sendo que o réu estava saindo de carro da sua residência quando foi abordado pelo Albranti, bem como ele foi liberado, entrou no carro e saiu logo em seguida. Adicionou também que Nicolas não chegou a correr da abordagem policial, como também esses fatos ocorreram entre às 22h00min e 22h30min.

Com efeito, André Cristiano Vargas, testemunha e proprietário de uma sorveteria, contou que, na data dos fatos, Andrei foi até sua sorveteria pedir por copos de 500ml, recordando que isto ocorreu depois das 22h00min, tal qual o réu estava em um carro de cor preta. Por fim, expressou desconhecer se o réu tem ou não envolvimento com o tráfico de drogas, bem como Andrei trabalha com troca de pneus e também com venda de bebidas em sua residência.

O réu, Gilberto Nicolas Manzato Forcin, negou a prática do crime, sustentando que, na data dos fatos, estava dentro de sua residência junto de sua esposa quando saíram de carro, por volta das 21h00min, em direção à casa de sua sogra para jantarem, ocasião na qual sua esposa esqueceu a bolsa contendo a pomada de seu filho, oportunidade em que ela ficou na casa da sua mãe auxiliando na janta enquanto Nicolas retornou a casa para buscar a bolsa, entre às 22h00min. Após, quando estava saindo de sua residência, foi parado por 02 (duas) viaturas policiais, momento em que foi abordado e liberado pelos policiais. Sem delonga, seguiu novamente em direção à casa de sua sogra, ocasião em que retornou a sua residência por volta das 01h00min. Na segunda-feira, logo pela manhã em sua residência, foi abordado pelo policial militar Albranti e ficou sabendo do ocorrido. Alegou que conhece o réu Andrei, já que é seu vizinho, como também prestou declarações na delegacia. Questionado pela acusação, detalhou que conhecia os policiais, pois era proprietário de um bar e os conheceu lá. Por fim, reforçou que Andrei não frequentava sua residência, inclusive nunca entrou nela.

O réu Maicon Andrei Scudilho, por seu turno, também negou o cometimento do delito, declarando que, na data dos fatos, havia trabalhado o dia todo em seu trabalho fixo e, à noite, por volta das 21h30min, foi de carro com o seu cunhado comprar copos em uma sorveteria próxima a sua residência, ocasião na qual não os encontraram lá e seguiram em direção ao "Dinho Corradini". Seguidamente, sua companheira ligou para seu cunhado relatando que o policial Albranti estava em sua residência perguntando por ele. Aludiu que ficou com medo e dirigiu-se até a casa de sua sogra, bem como retornou mais tarde quando sua esposa ligou avisando que os policiais não estavam mais lá. Ainda com medo, fechou o bar e ficou dentro de sua residência, inclusive trabalhou normalmente no final de semana até ser abordado em seu trabalho, na segunda-feira, pelo policial Albranti, tal como foi até a delegacia e prestou declarações ao delegado de polícia. Acrescentou conhecer Nicolas por morar perto de sua residência, mas não mantém forte amizade com ele, inclusive nunca entrou na casa dele. Recontou que foi buscar os copos por volta das 22h00min, sua esposa entrou em contato era 22h15min e retornou a sua residência depois da 00h00min. Por fim, complementou que conhece os policiais da cidade, pois trabalha em uma oficina e os policiais frequentam o local, tal como não tem problema com eles.

Anote-se que o depoimento dos policiais foi linear e isento de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa incriminação, mormente diante do contido no art. 202, do CPP de que toda pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e 772/682).

Sobre depoimentos prestados por policiais militares, eis a jurisprudência:

“Não há razões para desconsiderar a prova oral. A condição de policiais, por si só, não é suficiente para o afastamento do seu valor probatório. Afinal, o sistema processual não se filiou ao modelo da prova tarifada no qual os meios de prova registram valores préfixados. Ao contrário, a legislação filou-se ao princípio do livre convencimento racional. Assim, cabe ao julgador avaliar, com liberdade, as provas, confrontando-se com o quadro formado.

No caso em apreço, nada há nos autos a indicar desvio funcional que comprometesse a idoneidade das testemunhas. Ademais, os relatos são coincidentes. Assim, a prova fornecida pelos policiais é apta para a formação da convicção a respeito do crime imputado pela acusação. Trata-se, inclusive, de questão já superada na jurisprudência:

(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso 3. Se as instâncias ordinárias entenderam suficientes e indicaram os elementos de prova que levaram ao reconhecimento do crime de tráfico, é certo que não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, porquanto demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via estreita do writ (STJ - HC n.º 165.561-AM, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 02/02/2016).

Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade (STJ - HC n.º 404.514-PE, Relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06/03/2018).

De mais a mais, o sistema probatório abraçado em nossa legislação afastou-se do sistema de provas legais segundo o qual os valores probatórios são previamente indicados pelo legislador. Ao contrário, adotou-se o sistema do livre convencimento racional. Dessa forma, as provas devem ser avaliadas em seu contexto. As provas produzidas levam à reconstrução histórica dos acontecimentos. Esta reconstrução, por sua vez, é posta em confronto com a imputação. Se dela houver identidade que afaste a possibilidade de ocorrência de fatos diversos, haverá coincidência a qual é imperiosa da procedência e, portanto, do édito condenatório (16ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal 1525330-56.2019.8.26.0228 - Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI - Data de julgamento e publicação: 20/04/2021).

Ainda sobre o tema, se manifestou o Ministro Celso de Mello, no julgamento do Habeas Corpus nº 74.608-0:

“...os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles ao noticiar em Juízo suas atividades no combate à criminalidade, como tem assentado de forma pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar os acusados, ou em imputar falsamente a eles a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque não foi apontado nada que justificasse essa circunstância.

No que se refere ao fato típico, a descrição (conduta dolosa – resultados normativo e naturalístico – nexo de causalidade) atribuída aos corréus, contida na denúncia, adequa-se tipicamente (tipicidade), de acordo com os fundamentos desta sentença, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Quanto à ilicitude, o contexto fático típico (injusto penal) praticado pelos corréus (tráfico ilícito de drogas), em razão da lesão aos bens jurídicos tutelados (a saúde pública, primariamente, a vida, a saúde pessoal e a família, secundariamente), é contrário ao ordenamento jurídico, não se identificando, nos autos, nenhuma causa excludente.

No que se refere à culpabilidade, os corréus eram imputáveis, detinham possibilidade de compreender a ilicitude de sua conduta e, na situação em que se encontravam, podia ser exigido deles comportamento diferente, não se vislumbrando, nos autos, nenhuma causa excludente.

Diante desse conjunto probatório, no qual as versões apresentadas pelos corréus resultam isoladas nos autos, prevalecendo o depoimento dos policiais, que confirmaram, sob o crivo do contraditório, a existência da infração penal e sua respectiva autoria, corroborada pelas circunstâncias fáticas do fato (recebimento de informações; vigia do local; abordagem e reconhecimento dos réus; fuga de Maicon Andrei e eventual apreensão da bolsa contendo os entorpecentes).

Em que pese à prova testemunhal da defesa, tais depoimentos se mostraram frágeis e insuficientes quanto à negativa da autoria dos réus e; diante do contexto fático em que ocorreram os fatos, do teor dos depoimentos dos policiais, que narraram de forma segura e harmônica a conduta dos réus, tais quais sejam: que Andrei entrou na residência de Nicolas de mãos limpas e saiu com posse de uma bolsa; em abordagem policial, Andrei efetuou fuga jogando fora a bolsa, que ficou presa em uma concertina da casa vizinha; na direção oposta, Nicolas foi abordado pelo policial Moraes, nada de ilícito foi encontrado e, como seu parceiro Albranti solicitou reforço na abordagem do Andrei, Nicolas foi liberado e evadiu-se do local, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha José Antônio. Portanto, é tudo quanta basta para a certeza, sem qualquer espaço para dúvida, de que os corréus cometeram mesmo o crime imputado narrado na inicial acusatória.

No que toca à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não pode ser aplicada ao caso em tela, na medida em que ambos dedicam-se a traficância, o que demonstra que não se está diante de pequenos traficantes, mas sim de agentes do crime que integram teia organizada para prática delituosa, não ocupando mero acaso em situação de uso, tendo em vista a quantidade (3.086,37 [três quilos, oitenta e seis gramas e trinta e sete centigramas] de cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha) e natureza das drogas apreendidas (cocaína – sabidamente uma das substâncias ilícitas mais caras e de especial capacidade destrutiva):

[...] “O crack (subproduto da cocaína), não se olvide, é estupefaciente altamente viciante e vem causando grande preocupação na sociedade, em razão da proliferação de seu uso. O viciado em crack, na maioria das vezes, acaba deixando a família, perde o emprego e bens, passando a viver nas ruas e enveredando, muitas vezes, para a senda do crime, de modo a sustentar sua severa condição de dependência química. Aquele que vende entorpecente de tal natureza deve ser punido com mais rigor, em homenagem ao binômio reprovação-prevenção”. [...] (TJSP, Apelação nº 0004260-10.2011.8.26.0302 Jáú Des. Rel. PINHEIRO FRANCO).

Em consonância:

A quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e da jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...] (STJ, HC 578.782/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,

DJe 10/08/2020).

Isso porque os réus, além de ter volume de entorpecentes, o faziam em absoluto desacordo com sua capacidade econômica, o que leva à convicção de que a droga só pode ter sido adquirida à custa de vendas anteriores de droga, ou de que os réus estavam ligados à criminalidade organizada, sendo mais um elo de distribuição de entorpecente.

Trata-se de entendimento acolhido pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo (g.n.):

Apelação. Tráfico privilegiado. Art. 33, caput, e § 4º, da Lei Antidrogas. Recurso do Ministério Público. Pedido de majoração da pena-base e afastamento da redutora do § 4º. Pena-base majorada, com fundamento no art. 42 da Lei Antidrogas. Redutora do § 4º afastada. Grande quantidade de entorpecentes. Recurso provido. (TJSP; Apelação 0001502-02.2017.8.26.0576; Relator (a): Reinaldo Cintra; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2018; Data de Registro: 16/03/2018).

Nesse esteira:

Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Preliminar de nulidade pela ausência de fundamentação - Direito de recorrer em liberdade - Determinação de soltura pelo E. STJ - Apelo prejudicado. Preliminar - Prova ilícita - Inviabilidade - Incomprovado - Não utilização da prova para o embasamento da decisão condenatória - Afastamento. Pedido de absolvição pela insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Recurso não provido. Fixação da pena-base no mínimo legal - Possibilidade - Conduta social, culpabilidade e lesividade decorrente da natureza e quantidade da droga não são desfavoráveis - Apelo não acolhido. Tráfico privilegiado - Prática de ato infracional análogo ao delito de tráfico de drogas - Dedicção à atividade criminosa caracterizada - Recurso não provido. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos - Impraticabilidade pelo quantum da pena aplicado. (TJSP; Apelação Criminal 0000307-05.2018.8.26.0557; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Olímpia - Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2022; Data de Registro: 08/02/2022).

Assim, não preenchido um dos requisitos para a concessão da benesse legal (não dedicação a atividades criminosas e não integração à organização criminosa), sua aplicação fica inviabilizada.

Portanto, verificada a conduta dos acusados, suas condenações são de rigor, razão pela qual passo a lhes individualizar a pena.

3. APLICAÇÃO DA PENA

Passo a dosar a pena, observando o sistema trifásico do art. 68, do CP e art. 42, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

Aprecio, assim, as circunstâncias judiciais da primeira fase.

No que diz respeito à culpabilidade, que deve ser entendida como a capacidade do autor de perceber os fatos e de se determinar de acordo com eles e a reprovação social que sua conduta merece, tem-se que não há razões para valorizar a conduta negativamente, para além dos ditames mínimos legais.

A análise dos antecedentes deve observar o disposto no art. 5º, inciso LVII, da CF, ou seja, considera-se como tal a condenação transitada em julgado que não configure reincidência, sempre observando o princípio da não culpabilidade, conforme é consagrado pela jurisprudência pátria. Na espécie, conforme fls. 74/75 e 77/78, os

réus são primários;
Inexistem elementos acerca da conduta social dos agentes;
A afirmação a respeito da personalidade do agente, consubstanciada na prática do próprio crime a ele imputado, se desvinculada de outros elementos que demonstrem a má índole dos acusados, não sendo hábil a justificar o aumento da pena-base;
Quanto aos motivos do crime, acredito que não escapam à normalidade em se tratando de crimes dessa natureza, o que já foi levado em consideração pelo legislador por ocasião da criação do tipo penal, razão pela qual deixo de considerar essa circunstância em desfavor dos réus;
As circunstâncias e consequências do delito também não justificam acréscimo;
Por fim, não há que se falar em comportamento da vítima em tal espécie de delito (crime vago).
Passo à dosimetria das penas.

DO RÉU MAICON ANDREI SCUDILHO

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

O delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tem como pena privativa de liberdade de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, atento às circunstâncias previstas no artigo 59, caput, do CP, vislumbro a valorização negativa mínima da circunstância da culpabilidade, razão pela qual aplico a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, pena-base de 05 (cinco) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, de modo que, mantenho a pena-intermediária nos moldes atribuídos na primeira fase;

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não ostenta os requisitos legais para tal benefício. Razão pela qual torno a pena-definitiva nos moldes acima aplicados.

DO RÉU GILBERTO NICOLAS MANZATO FORCIN

Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

O delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 tem como pena privativa de liberdade de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na primeira fase, atento às circunstâncias previstas no artigo 59, caput, do CP, vislumbro a valorização negativa mínima da circunstância da culpabilidade, razão pela qual aplico a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, pena-base de 05 (cinco) anos, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem aplicadas, de modo que, mantenho a pena-intermediária nos moldes atribuídos na primeira fase;

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de diminuição ou aumento de pena a serem aplicadas. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porque o réu não ostenta os requisitos legais para tal benefício. Razão pela qual torno a pena-definitiva nos moldes acima aplicados.

Do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade

Para se aferir qual o regime inicial para o cumprimento da pena, deve o julgador considerar 03 (três) critérios: o quantum da pena, as condições pessoais do apenado quando da análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP e eventual reincidência do réu (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).

Aliado a isso, o art. 387, § 2º, do CPP determina que o tempo de prisão provisória

deva ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

À vista do quantum da pena aplicada e por não se tratar de crime equiparado a hediondo (conforme HC 118533/MS – STF – Rel. Min. Carmem Lúcia), estabeleço, pois, a ambos os réus, o REGIME SEMI-ABERTO para início do cumprimento da pena de reclusão, que faço com fulcro no art. 33, §2º, alínea “b” do CP.

Art. 387, § 2º, do CPP

Não há falar em aplicação da regra prevista no art. 387, § 2º, do CPP (detração penal) neste momento, porquanto o benefício não se confunde com progressão de regime; e, ainda, a matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, conforme entendimento sedimentado da jurisprudência do STJ (HC 443.498/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 15/06/2018).

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Ressalte-se que, considerando a quantidade da pena definitiva aplicada, que supera 04 (quatro) anos, é fator impeditivo da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, do CP.

Da suspensão condicional da pena “sursis”

Pelos mesmos fundamentos supra, inviável a aplicação do art. 77, do CP.

Da pena de multa

Fixo o valor do dia-multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do CP, sendo que o valor do dia-multa deverá ser objeto de correção monetária, na forma do art. 49, § 2º, do CP.

Da indenização mínima

Em função de o delito praticado ser classificado como crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação de valor para reparação civil de ofendido (art. 387, IV, do CPP).

4. DISPOSITIVO

Com supedâneo no exposto e no art. 387, do CPP, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar:

I) MAICON ANDREI SCUDILHO à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, no regime inicial SEMI-ABERTO, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

II) GILBERTO NICOLAS MANZATO FORCIN à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, no regime inicial SEMI-ABERTO, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por violação do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

“Status Libertatis”: Não estão presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da decretação da prisão preventiva, cumprindo ressaltar que, neste processo, os réus permaneceram soltos durante toda a instrução penal. Portanto, concedo-lhes o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

5. DISPOSIÇÕES FINAIS

Expeça-se a guia de recolhimento provisória, e, oportunamente, com o trânsito em julgado, complemente-se, com a expedição da guia de recolhimento definitiva. Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes

apreendidos, nos termos dos arts. 50, § 3º e 50-A da Lei nº 11.343/06, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça. Expeça-se certidão de honorários ao(s) defensor(es) dativo(s), nos termos do Convênio DPE-OAB/SP para essa espécie processual.

Após trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao IIRGD;
- b) oficie-se ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do(s) réu(s), conforme disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, e na Súmula 09 do Tribunal Superior Eleitoral;
- c) intime-se para pagamento da pena de multa;
- d) condene os réus, ainda, ao recolhimento das custas do processo, no importe de 100 (cem) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003), nos termos do art. 804, do CPC, entretanto, por estarem assistidos por defensor dativo, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC;
- e) no mais, cumpram-se as disposições constantes do Código de Normas da e. Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo, naquilo que for cabível.

Sentença registrada eletronicamente (arts. 389, do CPP e 72, §§ 4º e 6º, das NSCGJ). Publique-se (art. 389, do CPP). Intimem-se (arts. 390 e 392, do CPP). Certifique-se (art. 72, § 5º, das NSCGJ).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Bariri, 29 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA